

1501499-93.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... haxixe) para fixar a pena-base dos acusados, pelo delito de tráfico, 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, e, para o crime de associação para o tráfico, em 8 meses, o que se mostra proporcional e razoável.

5. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501499-93.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501499-93.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2294243/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 14884528 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3301/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2294243 - 02º

D.P. PIRACICABA, 3301/20/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2294243/2020 - 02º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

GUSTAVO VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de 2020, nesta cidade e comarca, transportava, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 29 invólucros com fragmentos vegetais contendo a substância entorpecente Tetrahydrocannabinadiol (THC), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, na mesma ocasião, na Rua Virgílio Furlan, nº 45, nesta cidade e comarca, o acusado tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 14 invólucros com fragmentos vegetais contendo a substância entorpecente Tetrahidrocannabinidiol (THC); 1 porção de haxixe (produto que também contém o THC); 6 comprimidos de ecstasy (possivelmente metilenodioximetanfetamina); e 2 invólucros contendo diversas unidades de LSD (possivelmente Dietilamida do Ácido Lisérgico), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares patrulhavam pela rua Virgílio Furlan, quando suspeitaram da atitude de GUSTAVO enquanto conduzia o veículo VW Jetta, de placas EYQ-2788. GUSTAVO foi abordado pelos PMS ao sair do veículo e adentrar um bar. Na sequência, o veículo foi revistado.

No interior do veículo, os policiais localizaram e apreenderam 29 porções de maconha, duas balanças de precisão, diversos sacos plásticos e a quantia de R\$ 290, proveniente do tráfico.

Descoberto que GUSTAVO transportava drogas no veículo, foi ele entrevistado sobre o achado e admitiu que se dedicava ao tráfico: informou que comprou um "tijolo" de maconha e que o fracionava para vender a terceiros.

Assim, os PMS rumaram à casa do réu onde, autorizados pelo pai dele (fls. 03), localizaram e apreenderam mais drogas e petrechos relacionados, a saber: 14 porções de maconha; 1 porção e haxixe; 6 comprimidos de ecstasy; 2 invólucros com várias unidades de LSD; 4 facas, 2 rolos de plástico filme; anotações relativas ao comércio ilícito, e R\$ 927,00 obtidos com o crime (fls. 49).

Narra, por fim, a denúncia que as 43 porções de maconha (THC) têm massa de 763,3g e que o haxixe (THC), de aspecto resinoso, tem massa bruta de 10,8g.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 204). Defesa preliminar apresentada às fls. 227/232. Após, a denúncia foi recebida (fls. 238/239) e o réu foi citado (fls. 265).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e três pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito. Pediu o afastamento do privilégio e a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena corporal.

A Defesa arguiu, em preliminar, a ilicitude da ação dos policiais. No mérito, pediu a absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a tese defensiva de ilicitude da ação dos policiais em decorrência da realização das diligências sem mandado judicial.

No caso dos autos havia fundadas suspeitas da prática de crime pelo réu a autorizar a abordagem policial.

De fato, conforme revelou a prova oral que adiante será analisada, o réu foi visto trafegando na via pública e, ao notar a aproximação da viatura, imediatamente mudou o comportamento, parando abruptamente na frente de um bar, desembarcando do veículo e tentando ingressar no estabelecimento, com a nítida intenção de se afastar do automóvel e de eventual abordagem. Isso despertou a ação dos policiais, que, percebendo situação indicativa da prática de ilícito penal, resolveram abordá-lo. Notaram muito nervosismo por parte dele, os policiais o indagaram se trazia algo ilícito consigo. O réu, então, admitiu que transportava drogas no veículo e, assim, os policiais realizaram a busca veicular.

Diante desse contexto indicativo de que o réu estava em situação típica da prática de crime de tráfico de entorpecentes, verifica-se licitude na ação dos policiais de realização da busca veicular, onde encontraram 29 invólucros de maconha, além de balanças de precisão, sacos plásticos e dinheiro.

O tráfico de drogas é crime permanente e, havendo indícios de que o réu estava transportando substância ilícitas, não há qualquer razão para invalidar a sua abordagem e revista pessoal.

Em caso análogo, assim decidiu o C. STJ:

“A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R\$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região. (...)” (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Quanto ao que ocorreu posteriormente, no desdobramento das diligências, também não se verifica ilicitude.

Com efeito, conforme a prova produzida, após o encontro do entorpecente no veículo do réu, este, colaborando com os policiais, confessou a eles que guardava entorpecentes em sua casa, para onde se dirigiram e, com autorização de seu genitor, encontraram o restante dos entorpecentes descritos na denúncia, bem assim dinheiro em notas trocadas e anotações indicativas de contabilidade.

Nesse contexto, e considerando os uníssonos depoimentos dos policiais de que houve prévia autorização do genitor do réu para ingresso em sua residência, os quais coincidem com o depoimento de Marcos José Vieira (fls. 03) neste mesmo sentido, não há dúvidas de que houve essa prévia permissão para ingresso na casa e que ali se ocorria o crime permanente de tráfico de entorpecentes, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”.

Anote-se que a Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem prévia autorização judicial em casos excepcionais, como aqueles em que há flagrante delito, como na hipótese dos autos.

Neste sentido dispõe o artigo 5º, inciso XI:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” - gn.

No caso dos autos, as provas são muito seguras de que havia fundada suspeita da prática de tráfico pelo réu, bem assim que houve prévia autorização para ingresso

na residência do réu, o que afasta a arguição de ilicitude trazida pela nobre Defesa.

No sentido de que, em casos como esse, inexistente a apontada ilicitude, é farta a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns recentes julgados:

“Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. 1. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e a autorização para ingresso domiciliar dada pela sua esposa. Apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel após consentimento da moradora. Permissivo constitucional. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 2. Materialidade demonstrada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas desacompanhadas de outros elementos indicativos da destinação comercial. Negativas do réu. Diante das dúvidas quanto à destinação comercial, há de prevalecer a situação mais favorável à defesa diante da supremacia do princípio da presunção da inocência. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 3. Dosimetria. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 4. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP - Apelação Criminal 1500145-58.2020.8.26.0623. 16ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli - j. 11/02/2021) - g.n.

“HABEAS CORPUS - Tráfico Ilícito de Drogas - Preliminar - Nulidade - Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO - O ingresso dos policiais na residência a priori foi franqueada pelo paciente, após denúncia anônima. Diante de tal contexto, é certa a situação de flagrante, não havendo falar em nulidade da prisão por violação de seu domicílio. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar - IMPOSSIBILIDADE - A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada”. (TJSP. Habeas Corpus Criminal 2095991-37.2021.8.26.0000. Relator: Paulo Rossi. 12ª Câmara de Direito Criminal. J: 02/06/2021) g.n.

“Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Ao contrário do aventado pelo patrono, o próprio acusado, ao ser abordado pelos policiais militares e após tomar ciência acerca de um mandado de prisão civil expedido em seu desfavor, voluntariamente informou a existência de drogas em sua residência, a fim de preservar a esposa e o filho, consoante suas declarações em ambas as fases da persecução penal. Entrada franqueada. No mérito, a condenação deve subsistir, estando escorada em sólidos elementos. Apreensão, no interior da residência do réu, de 78 porções de cocaína, com peso total aproximado de 76,06 gramas, 41 porções de ecstasy, com peso de 44,65 gramas, e 21 porções de crack, com peso de 17,74 gramas, além de uma balança de precisão, dois aparelhos de telefone celular, 1.200 pinos plásticos do tipo

conhecido como eppendorfs, uma caneca plástica vermelha contendo diversas embalagens plásticas transparentes e duas lâminas de barbear com resquício de cocaína. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Réu confesso. Inequívoca posse das substâncias para fins mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pleito de reexame das penas e do regime. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Incidência do tráfico privilegiado. Aplicação em patamar máximo. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo. Expeça-se o alvará de soltura clausulado em favor de Wagner Roberto Brunasse". (TJSP. Apelação Criminal 1500056-13.2020.8.26.0598. Relator: Guilherme de Souza Nucci. 16ª Câmara de Direito Criminal. J: 01/06/2021) - g.n.

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelo:

- a) boletim de ocorrência de fls. 15/19;
- b) auto de exibição e apreensão de fls. 10/14 e fotografia de fls. 49/54;
- c) auto de constatação preliminar de fls. 26/29, laudo de exame químico toxicológico de fls. 256/259, com resultado positivo para maconha e ecstasy em relação às substâncias apreendidas, e laudo pericial das balanças de precisão (fls. 260/262), nas quais foram encontrados resquícios de maconha.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06), o réu permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), disse que, no dia dos fatos, estava indo para casa com o carro de seu pai. Parou no bar, desceu e cumprimentou o proprietário. Logo os policiais chegaram e o abordaram. Revistaram-no e nada de ilícito encontraram em seu poder. Seu pai foi avisado da abordagem e rapidamente chegou no local. Os policiais conversaram com ele separadamente. Não ouviu o que falaram. Após, eles foram até sua casa na companhia de seu pai e lá, no interior de seu guarda-roupas, encontraram todas as drogas descritas na denúncia. Disse que as guardava para um amigo traficante. Fez isso sem ganhar nada, somente pela amizade. Declarou-se arrependido de sua conduta. Por fim, afirmou que trabalha na lanchonete do pai, no bairro Pauliceia, que na época dos fatos fumava maconha e que o carro é financiado, não tendo sido transferido para o nome dele em razão da dívida.

A versão do réu afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação sistema SAJ), o policial militar Ivan de Oliveira disse que estava com seu colega de farda realizando patrulhamento de rotina no bairro Pauliceia e, quando entraram na rua Virgílio Furlan, viram um veículo VW Jetta trafegando em baixa velocidade. Notaram que seu condutor, ao perceber a aproximação da viatura, imediatamente mudou o comportamento, estacionou bruscamente o automóvel, desceu e entrou rapidamente em um bar. Suspeitaram que ele estava praticando algum ilícito e o abordaram, identificando-o como Gustavo Vieira. Como ele estava muito nervoso, questionaram-no se tinha algo de ilícito e ele admitiu que trazia drogas no carro. Com ele não havia nada de ilícito, mas, no interior do veículo, encontraram 29 porções maiores de maconha, balanças de precisão, sacos plásticos e R\$ 290,00 em notas trocadas. O réu contou que havia adquirido um "tijolo" de maconha, com o

intuito de fracioná-lo e revender o produto. Ele ainda informou que guardava mais drogas em sua casa, que ficava em local próximo. O genitor do acusado chegou ao local dos fatos durante a busca no automóvel e tomou ciência do encontro das drogas no carro, bem assim que o filho havia confessado que estava traficando e que guardava mais entorpecentes em sua casa. O genitor aparentava ser uma pessoa de bem e imediatamente autorizou a polícia a realizar uma busca em sua residência, acompanhando a equipe até lá e durante as buscas. No quarto do réu, encontraram mais 14 porções de maconha, além de uma porção de haxixe, seis comprimidos de ecstasy, duas tiras de substância aparentando ser LSD, quatro facas e dois rolos de plástico filme, bem assim R\$ 927,00 em dinheiro e anotações condizentes com comércio de drogas.

No mesmo sentido as declarações prestadas perante a Autoridade Policial (fls. 05) e sob o crivo do contraditório (gravação) pelo policial militar Amauri do Carmo Ramos.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que nada tinha contra eles.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro

FELIX FISCHER – j. 23/10/2018) g.n.

“Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO – j. 11/09/2020) – g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Contrariamente, estão em consonância com o que declarou o pai do acusado, Marcos José Veira, perante a Autoridade Policial (fls. 03), o qual afirmou que soube da abordagem policial de seu filho, do encontro de drogas no carro que ele conduzia e autorizou a busca em sua residência porque sabia que ele guardava mais entorpecentes lá.

Quanto às testemunhas arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos, limitando-se apenas a descrever a conduta e os antecedentes do acusado.

De fato, Luís Carlos Rodrigues da Silva (gravação) disse que conhece o réu há 15 anos, pois o pai dele tem uma lanchonete na frente de seu comércio. Ele sempre trabalhou com o pai, o que faz até hoje.

Valdemir Roque Machado (gravação) declarou que conhece o réu há mais de 14 anos, pois sempre moraram no mesmo bairro, Pauliceia. Afirmou que tem uma oficina de torneiro mecânico na mesma rua da lanchonete do pai do réu, onde o réu sempre trabalhou.

Marcelo Marques da S. Júnior (gravação) afirmou que conhece o réu 13 ou 14 anos, pois o pai dele tem uma lanchonete e o réu sempre trabalhou lá. Recentemente, o réu assumiu o controle do estabelecimento, pois o pai dele ficou doente. Sabe que o carro Jetta é do pai do réu.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu transportava, tinha em depósito e guardava, para a entrega a terceiros, 43 invólucros de maconha, pesando 740g de massa líquida, seis comprimidos de ecstasy, pesando 3,6g de massa líquida e uma porção de haxixe, pesando 3,1g de massa líquida.

De fato, o réu foi surpreendido pelos policiais conduzindo um veículo e, após esboçar atitude suspeita, indicativa da prática de ilícito penal, em busca no seu automóvel, eles encontraram porções de maconha, além de petrechos comumente usados para fracionar e embalar a droga para a mercancia ilícita. Ademais, na residência do acusado, especificamente em seu aposento, encontraram mais drogas, petrechos relacionados ao tráfico e dinheiro em notas trocadas.

Registro que o destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência policial, mas também em razão da grande quantidade de drogas, sua diversidade e pela própria confissão judicial feita pelo réu de que eram destinadas à entrega a terceiros.

Além disso, junto com as drogas havia balanças de precisão (com resquícios de entorpecentes – conforme laudo de fls. 260/262), objetos comumente utilizados por traficantes para pesar as substâncias para a venda.

E também havia dinheiro em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada pela Defesa, ressaltando-se que o réu sequer apresentou justificativa para a posse dos valores junto com os entorpecentes, presumindo-se, nesse contexto, ser fruto do comércio ilegal de entorpecentes e, inclusive, ensejando seu perdimento em favor da União.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A fim de se evitar o “bis in idem”, a diversidade de drogas e a quantidade mais expressiva não serão sopesadas nesta fase para justificar o aumento das penas-base, pois servirão de fundamento para a redução das penas em fração menor pelo privilégio.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão da autoria do crime, mas deixo de reduzir as penas, pois circunstâncias atenuantes não autorizam a redução aquém do mínimo legal.

Não há causas de aumento de penas.

Não havendo comprovação da ocorrência de algum dos impeditivos do privilégio elencados no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, possível a aplicação do redutor de que trata essa norma.

Registro que, conforme mencionou o E. TJSP na decisão proferida no habeas corpus impetrado em favor do acusado (fls. 167/168) e no acórdão respectivo, na hipótese dos autos, a existência de petrechos relacionados ao tráfico e quantidade de drogas, embora mais expressiva, por si sós, não constituem indicativos de contumácia no tráfico a impedir o privilégio.

Quanto às anotações apreendidas, não foram submetidas à perícia de conteúdo ou grafotécnica, a fim de se verificar se promanaram do punho do acusado e se, realmente, tinham conteúdo relacionado à contabilidade do tráfico. Não servem, portanto, para demonstração da habitualidade delitiva.

Por outro lado, o réu comprovou que, à época, exercia atividade lícita.

Por fim, ele nunca teve qualquer registro criminal, nem mesmo inquéritos policiais em andamento ou que foram arquivados, muito menos registros de atos infracionais enquanto menor de idade (fls. 57).

Neste contexto, não há como se falar que se trata de traficante de maior envergadura ou que vem reiterando em atividades criminosas, bem assim que teria envolvimento com organizações criminosas.

Destarte, possível a aplicação do privilégio, com a diminuição das penas, mas não no percentual máximo permitido, eis que a quantidade de drogas apreendidas é bastante expressiva, fato que, aliado à circunstância de haver diversidade de entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico e dinheiro, indicam se tratar de conduta mais danosa e mais lesiva ao bem jurídico tutelado.

Nesse contexto, possível a redução das penas em 1/3, perfazendo três anos e quatro meses de reclusão e trezentos e trinta e três dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de “envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a

realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Tendo em vista que não há prova segura de que o veículo apreendido era de propriedade do pai do acusado e restando comprovado que o bem estava na posse do réu e que foi por ele utilizado como instrumento para o transporte das drogas, pode ser ele confiscado e decretado seu perdimento em favor da União, consoante o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, não se exigindo, nesses casos, habitualidade, nem mesmo que o veículo esteja preparado especificamente para o transporte da droga, conforme tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 647 da Repercussão Geral: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE nº 638.491/PR. Relator Min. Luiz Fux, Dje. 23/08/2017).

Neste sentido julgados do E. TJSP:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da acusação e da Defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Pena. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas na fração de 2/3. Possibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Possibilidade. Regime inicial aberto mantido. Perdimento dos bens e valores. Mantido perdimento do veículo e do dinheiro. Instrumento e produto do crime. Restituição somente do telefone celular. Recursos parcialmente providos". (TJSP -Apelação Criminal 1500705-22.2019.8.26.0627. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luiz Fernando Vaggione - j. 07/04/2021).

"Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença absolutória Recurso Ministerial, buscando a condenação do réu nos termos da denúncia. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito - Apreensão de 186 porções de cocaína (peso aprox. de 271 gramas) - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos entre si, e em relação àqueles prestados perante a Autoridade Policial - Descrição detalhada da prática da traficância pelo acusado - Versão do réu que não restou comprovada nos autos - Condenação como medida de rigor. Dosimetria da pena - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal - Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes - Na terceira fase, ausentes causas modificativas. Fixação de regime inicial fechado, único compatível com o delito em tela, diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta do réu, em concreto - Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque falta amparo legal, e porque as circunstâncias também não recomendariam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei de Drogas. Perdimento de bem em favor da União - Veículo utilizado para a prática da traficância de drogas. Recurso Ministerial provido para condenação do réu, nos termos da denúncia. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente" (TJSP - Apelação Criminal 1500365-60.2019.8.26.0536. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Ely Amioka - j. 07/04/2021).

O C. STJ também já se pronunciou neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANSNACIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se trata de julgamento virtual. A hipótese é de julgamento telepresencial, que segue os mesmos comandos normativos do julgamento presencial. O Agravo Regimental não comporta, na esfera penal, sustentação oral nem requer intimação prévia, consoante o Regimento Interno do STJ (arts. 159 e 258). Pedido de adiamento indeferido.

2. Não se pode falar em cerceamento de defesa no julgamento de origem, uma vez que houve a intimação dos patronos acerca do julgamento realizado e, além disso, para garantir a defesa dos acusados, foram nomeados dois defensores dativos para a sessão.

2. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, com base na análise no vasto conjunto de provas dos autos, entendeu que ficaram comprovadas, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas pelos acusados, mantendo a condenação deles pelos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a transnacionalidade do crime.

Assim, concluir pela absolvição dos acusados e pela nacionalidade do crime, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade da droga apreendida (FATO III - apreensão de 5,472kg de skunk e 1, 789kg de haxixe) para fixar a pena-base dos acusados, pelo delito de tráfico, 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, e, para o crime de associação para o tráfico, em 8 meses, o que se mostra proporcional e razoável.

5. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Assim, havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. 6. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg nos EDcl no Resp 1866666/SC. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 15/09/2020) - g.n.

Conforme exposto acima, também restou comprovado que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, de modo que igualmente possível seu perdimento em favor da União, nos termos do artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06.

Os demais bens apreendidos podem ser liberados, porquanto não demonstrado que eram produto do crime ou instrumento para ele.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu GUSTAVO VIEIRA a cumprir três anos e quatro meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar trezentos e trinta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

2) DECRETO o PERDIMENTO do veículo e do dinheiro apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06.

Defiro a liberação dos demais bens apreendidos, comprovada a propriedade.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA